Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 2ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº 0045866-91.2023.8.17.2001

AUTOR(A): ELBENE MARIA BRITO DA SILVA

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc.

ELBENE MARIA BRITO DA SILVA, legitimamente habilitada, propôs **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional** em desfavor da **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**, devidamente qualificados.

Alega a autora que foi diagnosticada com "neoplasia maligna da mama" (CID10 – C50) e realizou procedimento de mastectomia de mama esquerda e atualmente foi diagnosticada com câncer na mama direita, estágio II, com KI67 elevado (aproximadamente 90%), que indica o grau de agressividade da doença.

Afirma a demandante que o seu médico assistente, o Oncologista Clínico, Dr. Thiago Lourenço Apolinário (CRM/PE 17.735), diante dos eminentes riscos, apontou a necessidade de dar início ao tratamento quimioterápico a base de quimioterápicos associado a imunoterapia com Pembrolizumabe 200mg. Ao solicitar o tratamento junto a ré teve o pedido indeferido o referido medicamento, sob a alegação de não possuir cobertura.

Assim, diante da negativa não restou alternativa senão a propositura da presente medida judicial requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, no sentido de que seja determinado: ***"que a Empresa Ré seja compelida a arcar com as despesas do medicamento solicitado pelo médico assistente do Autor, quais sejam Pembrolizumabe 200mg (Endovenosa a cada 3 [três] semanas por 17 [dezessete] ciclos) de forma irrestrita;"***

Tutela deferida, conforme se observa da decisão de ID 131527513, e mantida em sede de julgamento de agravo de instrumento, conforme se observa do acórdão de ID 156565742.

Após, devidamente citada, a parte demandada apresentou a contestação de ID 138552572, na qual defende que o medicamento tem caráter experimental e que houve respeito às normas da ANS; defende a legalidade das cláusulas contratuais; a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Réplica de ID 141367277 na qual a autora reitera os termos da inicial.

Houve alegação de descumprimento, tendo sido efetuado o bloqueio de ativos na conta da demandada para fins de cumprimento da decisão proferida em sede de tutela e confirmada em recurso.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório, pelo que, **DECIDO**.

1. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Entendo ser hipótese que dispensa dilação probatória, uma vez que os elementos presentes, inclusive a prova documental, já são suficientes para emitir a sentença antecipadamente, entendo pela aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a confortar o julgamento antecipado da lide, consolidado pelas seguintes orientações da jurisprudência que interpretavam dispositivo semelhante do Antigo Código de Processo Civil:

> "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder." (STJ-4ª turma, Resp 2.832-RJ, DJU 17.9.90, p. 9.513).

> "Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia." (STJ-4ª Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, DJU 3.2.92, p. 472).

2. DA APLICAÇÃO DO CDC

É inquestionável que o contrato firmado entre as partes para prestação de serviço de saúde insere-se no rol de contratos de consumo, implicando a aplicação da Lei nº 8.078/90, eis que a autora se enquadra na definição de consumidor (art. 2º), e a ré na de fornecedora (art.3º), por exercer suas atividades de modo habitual, bem como o serviço contratado na definição de produto (art. 3º, §1º). Sendo a hipótese, inclusive, de aplicação da Súmula nº 608, do STJ, que assim dispõe: ***"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90) aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*** Aplicável, portanto, o CDC.

3. DO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PRETENDIDO

Conforme assentado no julgamento proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do no EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico, desde que ***"(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde"*** (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx).

No caso em análise, o laudo do médico assistente, ID 131455498, é claro ao informar que a autora é portadora de câncer de mama a direita, estágio II e ainda afirma a urgência do tratamento: "*atrasos no início do tratamento com o Pembrolizumabe acarretarão em redução da eficácia do tratamento, aumento o risco de morte da paciente, portanto, solicito EXTREMA IJRGÊNCIA, na liberação do tratamento com Pembrolizumabe*." Para além disso, não se trata de um simples medicamento indicado para aliviar sintomas, **mas, sim, de droga prescrita em razão de tratamento de câncer de mama que apresentou avanço**, visando controlar o mesmo, evitando, com isso, complicações da doença e do quadro de saúde da autora.

Nesse contexto, a limitação imposta pelo réu, colocando obstáculos na cobertura do tratamento que foi prescrito como meio adequado e indispensável à tentativa de salvaguardar a saúde da paciente, viola o próprio objetivo do contrato, o que não pode ser admitido. Além disso, uma vez havendo cobertura contratual para a doença da autora, o plano de saúde réu não pode se substituir aos médicos na opção terapêutica, sendo, portanto, ilegal a negativa do tratamento prescrito por profissional competente.

Portanto, em razão da injusta recusa de cobertura securitária pela empresa ré, em clara afronta à legislação pátria, **torna-se de fato necessária a confirmação, por meio de sentença, da tutela jurisdicional deferida nos autos (ID 131527513)**, de modo a preservar a saúde do autor e evitar-lhe o dano irreparável.

4. DOS DANOS MORAIS

No que tange aos danos morais, entendo ser ele devido.

A autora se submeteu a enorme desgaste para ter o tratamento considerado imprescindível para controle de doença grave, vez que, apenas após a interferência do judiciário, a parte ré arcou com o tratamento necessário à cura da sua moléstia, inclusive mediante bloqueio judicial de ativos.

Tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da segurada, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.

Saliente-se que, nesse caso, o tipo de dano prescinde de prova, pois decorre da própria situação, decorre do próprio fato, o qual é chamado de in re ipsa, independendo, portanto, de demonstração dos efetivos prejuízos.

Na doutrina de Carlos Alberto Bittar o dano moral decorre do simples fato da violação, sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois "*o dano existe no próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com efeito, corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova do dano moral. Não cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que sofreu, realmente, o dano moral alegado*" ("Reparação Civil por Danos Morais", Ed. RT, 1993, pp. 202-205).

No sentido do reconhecimento do ilícito em caso de indevida negativa de cobertura por empresas de seguro saúde, confira-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "*Pacificada, outrossim, a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele* (REsp 993.876/DF, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 18.12.07). E ainda: AgRg no Ag 846.077/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 18.7.07; REsp 880.035/PR, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 18.12.06; REsp 259.263/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 20.2.06" (STJ, Agravo nº 1.226628/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU 26.03.10).

No tocante ao *quantum*, a indenização deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o constrangimento causado à autora.

Para o atendimento dessa dúplice finalidade, no caso em exame, tenho como justo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o porte econômico da empresa ré e a condição de saúde da requerente quando da negativa.

5. DISPOSITIVO

Por esses fundamentos, com esteio no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora confirmando a decisão antecipatória exarada nos autos, para efeito de condenar a requerida a custear o medicamento "pembrolizumab", conforme prescrito pelo médico em ID 131455498; e a pagar, em favor da autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pela tabela do ENCOGE e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados desta decisão.

Por força da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas judiciárias e da verba honorária do patrono da autora, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Recife, 12 de janeiro de 2023

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA
12/01/2024 09:13:55
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 157762493

24011209135577800000154103371

IMPRIMIR GERAR PDF